

1501365-72.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... condenação dos réus pelo crime de tráfico e absolvição quanto à associação ao tráfico, enquanto a Defesa requereu sua absolvição em relação a ambos os delitos ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão e do tráfico privilegiado ao réu GABRIEL.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal merece ser julgada parcialmente procedente.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501365-72.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501365-72.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269447/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 20618165 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2220/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2269447 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MOREIRA FERREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

GABRIEL MOREIRA FERREIRA e LUCAS MOREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, combinados com o artigo 29 do Código Penal, na forma do concurso material de infrações (art. 69 do CP), porque, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 03 horas e 40 minutos, na Rua Abolicionista Aristides da Silveira Lobo, 76, Pinus do

Iriguassu, nesta cidade e comarca de Caçapava, agindo em concurso de agentes e com identidade de propósitos, previamente ajustados entre si e com outros indivíduos não identificados, para fins de tráfico, traziam consigo e guardavam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua Abolicionista Aristides da Silveira Lobo, no bairro Pinus do Iriguassu, nesta cidade e comarca, os réus, para fins de tráfico, tinham em depósito e guardavam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os réus, associaram-se para praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06. Os réus foram notificados (fls. 173 - Lucas Moreira; fls. 176 - Gabriel Moreira Ferreira), apresentaram defesa prévia (fls. 143/144), sendo recebida a denúncia em 02/12/2021 (fls. 165/167) e os acusados foram citados.

Durante a instrução (fls. 206/207), realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus, foi ouvida 01 (uma) testemunha de acusação, bem como foram os réus interrogados, sendo todos os depoimentos gravados pelo sistema de captação audiovisual. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação dos réus pelo crime de tráfico e absolvição quanto à associação ao tráfico, enquanto a Defesa requereu sua absolvição em relação a ambos os delitos ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão e do tráfico privilegiado ao réu GABRIEL.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal merece ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/13), Laudo de Constatação Provisória (fls. 52/56), Exame Químico-Toxicológico (fls. 202/205) e pela prova oral coligida.

A autoria dos acusados desponta nítida e indubitosa.

Em interrogatório judicial, o réu GABRIEL MOREIRA FERREIRA declarou que tem 23 anos; é solteiro; tem um filho; antes de ser preso, fazia alguns bicos; nunca foi condenado criminalmente. Quanto aos fatos, disse que eles são parcialmente verdadeiros. Declarou que, no dia, pegou emprestado o veículo de um amigo; já era tarde e convidou seu irmão Lucas para irem ao fluxo. Admitiu que havia um tablete de maconha no veículo. Como sabia do tablete de maconha, deu fuga com o carro, mas, na saída da Dutra, perdeu o controle e bateu na guia. Ao descer do veículo, os policiais chegaram disparando, razão pela qual ele e o irmão tentaram se evadir, mas foram detidos. Após vistoriarem o veículo e encontrarem a maconha, os policiais pediram o endereço de sua casa. Após, em diligências em um mato próximo a sua residência, os policiais acharam mais entorpecentes, porém, nega que essas drogas fossem suas, admitindo apenas a posse do tablete de um quilo de maconha encontrado no interior do imóvel. Esclareceu, porém, que seu irmão Lucas desconhecia a presença de drogas no veículo. Disse que a maconha iria ser vendida pelo interrogando para uma pessoa e que no veículo somente se encontravam o interrogando e seu irmão, não sendo verdade que outros indivíduos saíram correndo em fuga da polícia. Seu irmão saiu correndo, mesmo não sabendo das drogas no veículo, pois os policiais chegaram atirando e ambos ficaram desesperados. O local onde o restante das drogas foi encontrado é bem conhecido; trata-se de uma mata expandida conhecida da polícia onde já existiram outras operações. Não indicou aos policiais onde essas outras drogas estavam enterradas no matagal. Durante a fuga, seu irmão ficou desesperado e a todo momento o interrogando procurou tranquilizá-lo. Disse a Lucas que estava com um tablete de maconha no automóvel somente após o acidente com o veículo; seu irmão não o questionou o motivo pelo qual estava fugindo da polícia. Ficou algum tempo preso na viatura. Durante as diligências no bairro, havia pelo menos umas oito viaturas no mato, não sabendo dizer se havia policiais de Caçapava. Está arrependido do que fez.

Ao ser interrogado em juízo, o réu LUCAS MOREIRA declarou que tem 18 anos, é solteiro, não tem filhos, trabalhava como ajudante geral, já foi processado na Infância por tráfico. Quanto aos fatos, disse que, no dia, seu irmão o convidou para ir a um fluxo de rua, quando se depararam no caminho com uma viatura, razão

pela qual Gabriel empreendeu fuga, até vir a perder o controle do carro. Desceram do veículo, mas, ao ouvirem disparos de arma, começaram a correr, mas foram detidos pela polícia. Esclareceu, no entanto, que, no veículo, não foi achado nada de ilícito, pois a ele não foi mostrado nada pela polícia. Após foi colocado em outra viatura e indagados onde moravam. Ato contínuo, os policiais, pararam a viatura na frente de sua casa e outras no mato; depois disso, pegaram seus documentos e o interrogando foi colocado novamente na viatura e deslocado à delegacia. O interrogando não viu se os policiais encontraram drogas no mato. Durante a fuga não perguntou ao irmão o motivo pelo qual ele empreendeu fuga da polícia. Tampouco o perguntou o motivo dos disparos após se acidentarem com o automóvel. Saiu correndo, pois ouviu os disparos. Além do interrogando e de Gabriel, não havia mais ninguém no automóvel. Não ouviu Gabriel dizendo aos policiais que em troca de sua liberdade havia mais drogas no Pinus. Os policiais não tinham motivos para prejudicá-los. O interrogando não conhecia os policiais anteriormente. Sobre a contradição entre as versões de Gabriel (no sentido de que lhe contou sobre a presença de drogas no automóvel após o acidente e de que foi encontrado um tablete de maconha no porta-malas) reafirmou que nada lhe foi dito por Gabriel e que não viu nenhuma apreensão no automóvel. Não entendeu o motivo pelo qual foi conduzido à delegacia, esclarecendo que somente depois, na delegacia, veio saber por seu advogado que foi preso por tráfico.

O policial militar MARCO NASCIMENTO FAZZANI, sob o crivo do contraditório, disse que, no dia, estavam no Bairro Jardim São José Dois, em São José dos Campos, quando o indivíduo, ao avistar a viatura, empreendeu fuga sentido Dutra. Iniciou-se o acompanhamento até que no Km 125 da Dutra o veículo se perdeu (acidentou-se) e os indivíduos empreenderam fuga, mas foram detidos. Outros dois indivíduos conseguiram se evadir pela mata. Em busca pessoal, nada de ilícito localizaram com os réus, mas na busca veicular localizaram dois tabletas de maconha. Posteriormente, o mais velho, indivíduo tatuado e identificado como Gabriel, para tentar eximir o irmão, em troca de sua liberdade, disse que possuía mais drogas enterradas no Pinus, onde localizaram próximo à residência dos réus grande quantidade de maconha e cocaína prontas para a veda. Eram quatro pessoas no veículo. Não sabe dizer se a gravação da apreensão no matagal foi encaminhada ao delegado. A filmagem demonstra retirada da droga enterrada em um tambor. Somente o indivíduo tatuado assumiu o envolvimento com as drogas. A respeito dos indivíduos que se evadiram, os réus disseram que eram pessoas que conheceram no baile (fluxo). O indivíduo tatuado era o condutor do veículo e se apresentou como responsável pelo veículo. A abordagem se deu em patrulhamento de rotina, após o veículo empreender fuga de forma acelerada. Como se denota, policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando decidiram fiscalizar o veículo Hyundai i30, placa ERN-0336; deram ordem de parada, mas o veículo não obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, sendo acompanhados pela viatura. No entanto, na saída do Km 125 da Rodovia Presidente Dutra, o motorista perdeu o controle do veículo, momento em que quatro indivíduos desembarcaram do carro e saíram correndo. Apenas GABRIEL e LUCAS foram detidos. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, nas buscas no interior do automóvel, foi localizado no porta-malas as placas FQR-8580 (dianteira e traseira) e um tablete de maconha, com peso aproximado de 1.093 gramas, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 11/13).

Questionados sobre os fatos, GABRIEL informou que em um terreno na Rua Abolicionista Aristides da Silveira Lobo, no bairro Pinus do Iriguassu, havia drogas enterradas em um terreno. Os milicianos se dirigiram ao local indicado e localizaram grande quantidade de entorpecentes enterrados no local - 430 eppendorfs contendo cocaína, 1.180 pedras de crack, 220 porções de maconha - conforme auto de exibição e apreensão (fls. 11/13).

Pois bem!

Embora GABRIEL tente a todo custo eximir seu irmão LUCAS de culpa, é forçoso reconhecer que as versões dos réus são absolutamente inverossímeis e contraditórias.

Com efeito, GABRIEL disse em seu interrogatório judicial que somente avisou LUCAS a respeito da presença de drogas no veículo após desembarcarem do automóvel colidido

durante a fuga da polícia.

LUCAS, por outro lado, disse de forma vaga e imprecisa que GABRIEL em nenhum momento contou-lhe da presença de entorpecentes no veículo (sequer após o desembarque do automóvel!!!), argumentando que tentou se evadir da polícia após a colisão mercê dos disparos de arma de fogo sofridos.

Ademais, GABRIEL admitiu em seu interrogatório que foi apreendido um tablete de maconha no porta-malas do veículo, bem como outras drogas enterradas em um mato vizinho a sua residência, negando, porém, a posse e propriedade destas últimas substâncias.

Lado outro, LUCAS, sem a menor verossimilhança, disse que a ele não foi apresentado pela polícia nada de ilícito durante a abordagem veicular, insinuando (não mais do que isso) que não foram localizadas drogas no automóvel, tampouco no matagal próximo a sua residência.

A narrativa de LUCAS, além de contrariar a própria versão do irmão GABRIEL, colide com o relato dos policiais militares em ambas as fases da persecução criminal, segundo quem GABRIEL, a fim de ver livre o irmão, indicou que na Rua Abolicionista Aristides da Silveira Lobo, em um terreno próximo de sua residência, havia certa quantidade de drogas enterradas, local onde foram encontradas grande quantidade de entorpecentes, a saber: maconha, cocaína e crack.

Ademais, se LUCAS de fato não tivesse ciência e relação com os entorpecentes localizados no veículo conduzido por seu irmão, jamais teria se exposto ao risco de fugir da polícia, sob disparos de arma de fogo, após desembarcar do automóvel acidentado em plena Rodovia.

Qualquer cidadão de bem e sem envolvimento com o ilícito colaboraria com a polícia e seria o primeiro a tentar demonstrar sua inocência, jamais pactuando com a condução anormal e injustificada de um automóvel em plena rodovia, ainda que pelo próprio irmão.

Portanto, é mais do que evidente que LUCAS possuía ciência e, mais do que isso, envolvimento real e concreto com o tablete de maconha apreendido no automóvel conduzido por seu irmão GABRIEL, tudo levando a crer que os entorpecentes aos dois pertenciam e seriam comercializados no fluxo (baile funk) para o qual se dirigiam antes de serem abordados.

Além do mais, de acordo com os milicianos, em depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal, além dos réus, outros dois indivíduos se evadiram pelo mato após o veículo se acidentar durante a fuga, o que corrobora a conclusão de que LUCAS e GABRIEL (e possivelmente os demais agentes) estavam unidos para o cometimento do crime de tráfico de drogas.

Por fim, o réu GABRIEL assumiu a posse e propriedade das drogas apreendidas no veículo, porém, negou ser possuidor e responsável pelos demais entorpecentes apreendidos no matagal ao lado de sua residência.

A versão de GABRIEL não merece guarida, pois é inquestionável que os agentes militares jamais encontrariam aleatoriamente drogas enterradas em um matagal de grande dimensão se não fosse pela indicação precisa da localização pelo próprio réu.

Cumprе salientar que a condição de policial - seja militar ou civil - não invalida por si só seus testemunhos, pois não estão impedidos de depor e se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade, como toda e qualquer testemunha.

Afora isso, não foi produzida pela d. Defesa qualquer prova de suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de ter a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC nº 73.518-5 -

Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

O dolo de traficar dos acusados GABRIEL e LUCAS decorre da falta de explicação razoável dos réus acerca dos fatos, da expressiva quantidade de entorpecente transportado no veículo, da variedade das substâncias entorpecentes apreendidas em matagal vizinho a sua residência, da fuga dos demais comparsas e da utilização de veículo para transporte das drogas.

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

Considere-se, ainda, que "[...] não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido [...]" (RT 729/542).

Todavia, apesar de certa a traficância pelos acusados, não há elementos nos autos que demonstrem, com segurança, a presença de associação estável e permanente para o tráfico entre os acusados, isto é, o ânimo entre os acusados e os demais indivíduos que se evadiram para formar e organizar suas ações, previamente, destinadas à prática do comércio espúrio.

Lembre-se que para caracterização do crime de associação para o tráfico é necessário que se comprove o caráter estável e duradouro da associação, não bastando para tanto a existência de mero concurso de agentes, tal como no caso em apreço.

Nessa senda, confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÕES - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE - ABSOLVIÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - REPAROS - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

'Cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, as condenações dos réus são impositivas. Entretanto, somente se configura o delito autônomo de associação (art. 35 da Lei n.º 11.343/06) se houver efetiva comprovação da existência de vínculo associativo, com características de estabilidade e permanência, não sendo suficiente para a configuração do tipo em questão o concurso eventual de agentes. Logo, não comprovada a estabilidade da associação, a manutenção das absolvições por este crime é imperativa (...)" (TJ/MG - A.C. n.º 1.0701.07.197329-4/001 - Rel. Des. Eduardo Brum - j. 18/11/2008 - D.O.P.J. 25/11/2008, g.n.).

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade apenas do crime de tráfico de drogas, devem os acusados ser absolvidos do crime de associação ao tráfico e condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 c.c. artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, há de ser considerada a quantidade e natureza das drogas apreendidas nos autos (um tablete de maconha, com peso aproximado de 1.093 gramas, 430 eppendorfs contendo cocaína, 1.180 pedras de crack e 220 porções de maconha), com alto poder viciante, notadamente o crack e a cocaína, razão pela qual majoro as penas em 1/5 (um quinto), perfazendo o total de 06 (seis) anos de reclusão, além 600 (seiscentos) dias-multa.

A propósito: "O art. 42 da Lei n.º 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos" (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).

Ainda, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o

previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017.

No tocante à segunda fase de dosimetria, impõe-se reconhecer que ambos os réus são primários.

Com efeito, LUCAS não possui nenhuma condenação criminal definitiva (fls. 62/63).

Por sua vez, GABRIEL foi absolvido em definitivo pela E. Segunda Instância da condenação de tráfico que lhe foi imposta nos autos do processo de nº 1501022-47.2019.8.26.0618 (fls. 60/61).

Considere-se, outrossim, que embora parcial, a confissão de GABRIEL foi relevante à formação da culpa, de modo que procedo à compensação de tal atenuante com a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal, mantendo as penas fixadas na etapa anterior, consoante exegese do artigo 67 do Código Penal.

De igual modo, procedo à compensação da atenuante da maioria relativa do acusado LUCAS com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal, mantendo as penas acima estabelecidas, a teor do que dispõe o artigo 67 do Código Penal.

Ora, não se pode negar que GABRIEL e LUCAS se valeram de uma situação pandêmica e dramática vivenciada pela coletividade, notoriamente reconhecida como calamidade, para o fim de obter renda fácil, passando a se dedicar ao tráfico, em prejuízo ao bem jurídico tutelado pela própria norma, qual seja, a saúde e bem-estar da coletividade.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitivas as penas fixadas acima.

Incabível a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, pois a quantidade de entorpecentes apreendidos (um tablete de maconha, com peso aproximado de 1.093 gramas, 430 eppendorfs contendo cocaína, 1.180 pedras de crack e 220 porções de maconha), além de R\$196,00 em espécie e de um automóvel para transporte de drogas, evidenciam premeditação, dolo exacerbado e dedicação habitual de GABRIEL e LUCAS à atividade criminosa, situações incompatíveis com o benefício em tela.

É evidente que ninguém confiaria tamanha quantidade de drogas a um novato, a alguém sem experiência e que não tivesse comprometimento com o crime.

No que tange à inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, oportuno trazer o entendimento do C. Superior Tribunal de

Justiça:

“HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 12 DA LEI 6.368/76.

CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. EXCESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NEGATIVA DE MITIGAÇÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Inocorre constrangimento ilegal quando a Corte originária,

entendendo que a paciente não satisfazia as exigências para a aplicação da causa de especial redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da expressiva quantidade de droga apreendida em seu poder e do fato de dedicar-se à atividade criminosa, fundamentadamente denegou a ordem, mantendo a decisão do Juízo da Execução. 2. Para concluir-se de forma diversa, ou seja, que a condenada não se dedicava às atividades ilícitas, necessário o revolvimento de todo o conjunto

fático-probatório colacionado durante a instrução criminal, o que é incabível na via estreita do remédio constitucional. 3. Ordem denegada. (HC 93.680/SP, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 03/11/2008, g.n.)”.

A propósito, não configura bis in idem a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento do redutor, pois o montante de droga pode e deve ser utilizado como impedimento da incidência da minorante (Nesse sentido: AgRg no HC 475615/SP, Relator Ministro FelixFischer, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, J. em 4.12.2018).

Confira-se:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.

INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR O REDUTOR. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE ILLEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA (...). (STJ, HC 420904/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. em 28.11.2017).

Ademais, o réu LUCAS admitiu em seu interrogatório que possui passagem pela Vara da Infância e Juventude por tráfico de entorpecentes, pela qual cumpriu medida socioeducativa de liberdade assistida, conforme evidenciado pela certidão de fls. 62, o que reforça a conclusão de que o acusado faz do tráfico seu meio de vida desde a adolescência.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica da ré.

No mais, à vista da quantidade de pena aplicada aos acusados, superior a quatro anos de reclusão, bem como em face da insuficiência da medida, inviável a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, ex vi do disposto no artigo 44, I e III do Código Penal.

Com efeito, é forçoso reconhecer que quem no tráfico se envolve, tais como os réus e, sobretudo, nas circunstâncias em que foram presos, em poder de variada e considerável quantidade de drogas, sobretudo a cocaína e crack, com alto poder nocivo e viciante, já embaladas para venda, além de dinheiro em espécie e um automóvel para transporte de drogas, denota extrema periculosidade, a exigir maior rigor e energia em sua repressão, sob pena de se criar o caos social e o indevido sentimento de impunidade.

No sentido de que eventual substituição da pena corporal por restritivas de direitos não se revela suficiente para punir e prevenir condutas que tais, confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM ASSOCIAÇÃO.

CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE PROVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DIVERSIDADE IMPOSSIBILIDADE. 1. A caracterização do crime de associação permanente para o tráfico de entorpecentes, enquanto requisita o reexame do conjunto da prova é inadequado ao âmbito angusto do habeas corpus. 2. A consideração do magistrado sentenciante na individualização da pena de que o paciente 'pertence a uma hierarquia superior no tráfico de entorpecentes, coordenando os outros dois acusados na distribuição da droga na Região', para além de lhe serem desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, não são circunstâncias estranhas ao elenco do artigo 59 do Código Penal, sendo bastante à exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 3. A substituição da pena privativa de liberdade pela sanção restritiva de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal, enquanto resposta penal em natureza, está subordinada, inarredavelmente, ao princípio da suficiência. 4. Concluindo a Corte Estadual pela necessidade do réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, à luz de motivação excludente, em natureza, das condições da pena restritiva de direito, também recusa a substituição da pena privativa de liberdade, por necessária consequência, ante sua insuficiência. 5. Ordem parcialmente conhecida e denegada" (STJ, HC 31628/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 04/09/2007, DJe 04/08/2008) – destaque nosso.

Diante do quantum de pena aplicado aos réus, fixo o regime inicial semiaberto, tanto o mais porque não cumprida cautelarmente em prisão preventiva fração de pena que justifique a fixação de regime mais brando, conforme dispõe o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a presente ação penal e, em consequência, condeno GABRIEL MOREIRA FERREIRA e LUCAS MOREIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa, no

menor valor unitário, com correção na forma da lei, e absolvendo-os da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Conforme acima fundamentado, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos a ambos os réus.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei n.º 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Outrossim, observo que os réus não fizeram prova da procedência lícita da importância em dinheiro e do telefone celular apreendidos, já que não comprovaram o exercício de qualquer atividade laborativa que lhes propiciasse auferir rendimentos lícitos. Deste modo, conclui-se que são produtos do tráfico de entorpecentes por eles praticado e, por este motivo, com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e artigo 62 da Lei n.º 11.343/06, declaro, após o trânsito em julgado, o perdimento, em favor da União, da importância em dinheiro e do telefone celular apreendidos nos autos.

Quanto ao veículo apreendido, é bom lembrar que a Lei de Drogas em seu artigo 62 dispõe regras sobre a apreensão, arrecadação e destinação dos bens apreendidos ligados ao tráfico ilícito de entorpecentes, não exigindo a demonstração da origem ilícita do objeto, bastando que se comprove sua conexão com a prática do delito, tal como no caso concreto. Assim, havendo nexos etiológico entre a conduta imputada aos réus e o veículo empregado para a sua prática, já que os acusados transportavam um tablete de maconha, com peso aproximado de 1.093 gramas, no automóvel, é de rigor o perdimento do do veículo apreendido nos autos em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/2006.

Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, porquanto reforçados os pressupostos da prisão preventiva com a superveniência da presente condenação.

Servirá a presente sentença, por cópia assinada digitalmente, como ofício para a comunicação da condenação à unidade prisional em que recolhidos provisoriamente os réus, a fim de viabilizar a sua imediata transferência para estabelecimento adequado ao cumprimento da pena corporal.

Os réus deverão arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual nº 11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça(m)-se guia(s) de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (v) havendo defensor nomeado, expeça-se certidão de honorários em favor da advogada nomeada nos autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA